

0001783-67.2015.8.26.0045

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: NAIRA BLANCO MACHADO

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... também não estava envolvido nos demais roubos. Falou que no roubo em que foi condenado pegou dois anos e oito meses e no roubo dos autos nega a absolvição.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Ao cabo da instrução processual verifica-se a fragilidade probatória, sendo insuficiente a embasar a condenação dos réus pelo crime descrito na denúncia, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

1ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja - SP - cep 07400-000

0001783-67.2015.8.26.0045 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001783-67.2015.8.26.0045

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO HENRIQUE LEITE SANTOS e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). NAIRA BLANCO MACHADO

Vistos.

THIAGO HENRIQUE LEITE e RICARDO JAVANOVITE foram denunciados e estão sendo processados como incurso nas sanções previstas no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, incidindo a agravante do artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, porque no dia 28 de janeiro de 2015, por volta das 07h30min, na Rua Petróleo, n. 240, Copaco, nesta cidade de Arujá, os acusados, previamente ajustados e agindo com unidade de propósitos, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o automóvel Fiat/Palio Fire Flex, ano 2006, cor prata, placas MWG 5148 e seu respectivo CRLV, documentos pessoais e cartões de crédito, um violão marca Fender, um CPU, parca positivo, um aparelho celular marca Samsung, tudo avaliado em R\$ 25.000,00, em detrimento da vítima Davi Leite Cavalcante e de seus dois filhos, que contavam com nove e oito anos de idade. Narra a denúncia que no instante em que deixava sua residência na companhia dos filhos a vítima foi abordada pelos acusados. Em seguida, Ricardo, empunhando arma de fogo, exigiu que a vítima e seus filhos entrassem num quarto da residência. Ato contínuo, Ricardo amarrou as mãos e pés da vítima, mantendo-a cativa, juntamente com seus filhos, trancada no mencionado quarto. Por fim, Ricardo e Thiago empreenderam fuga em poder do veículo e demais bens (fls. 01-d /02-d).

Boletim de ocorrência (fls. 03/05). Auto de reconhecimento (fls. 09). Folha de antecedentes (fls. 320/324).

A denúncia foi recebida em 29 de outubro de 2015 (fls. 35).

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação (fls. 54/59, 111/116 e 118/121), sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 125).

Em audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu Thiago ao final (fls. 238, 290/293 e 360/362).

O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela improcedência da pretensão punitiva, visto que os elementos que fundamentaram a oferta da denúncia não se tornaram provas suficientes para a condenação. Observou que os réus foram presos por outro furto a residência e os policiais chegaram à conclusão de que seriam responsáveis pelo roubo deste feito. Entretanto, o policial Cláudio disse não mais recordar dos fatos e o policial Guilherme disse que teve contato com a vítima que disse que reconheceu os roubadores como sendo Thiago e Ricardo em um livro de fotografias. Salientou que a vítima não foi localizada, restando esgotadas as tentativas de intimação. Aduziu que o réu Thiago disse que não praticou os fatos e o réu Ricardo não confirmou a participação no roubo (fls. 362).

A defesa do réu Thiago pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP, sustentando a ausência de lastro probatório e aplicação do in dubio pro reo (fls. 372/373).

A defesa do réu Ricardo pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP, argumentando que a vítima não foi localizada e o réu negou a autoria do crime (fls. 396/397).

Vieram-me os autos conclusos para sentenciamento.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Os autos estão em ordem. Não há preliminar a ser apreciada ou nulidade a ser declarada. Logo, o feito está apto a ser julgado.

A pretensão punitiva estatal é improcedente.

A materialidade do delito de roubo restou comprovada pelo boletim de ocorrência e prova oral colhida.

A autoria, no entanto, é incerta.

Passo à análise da prova oral.

A testemunha Cláudio, policial civil, disse que não conseguiu encontrar em suas coisas sobre o processo, acredita que houve o reconhecimento fotográfico pela vítima. Aduziu que não foi quem fez o BO e quando tem o reconhecimento tem um álbum fotográfico de suspeitos e os réus devem ter sido reconhecidos nele. Salientou que não fez a prisão. Mencionou que consta no boletim de ocorrência que a vítima foi amarrada. Comentou que trabalhou em Arujá entre 2014 e 2015 e muitos roubos à residência foram esclarecidos graças aos álbuns fotográficos.

A testemunha Guilherme, policial civil, disse recordar que no dia dos fatos a vítima disse que tinha condição de reconhecer os autores e visualizando o álbum fotográfico reconheceu como autores os réus Thiago e Ricardo. Acrescentou que foram feitas investigações de praxe para localizá-los. Complementou que o réu reconheceu com certeza. Disse não recordar se foi apreendido objeto.

O réu Thiago disse que tem 24 anos, está preso por porte de arma, estudou até o terceiro colegial, é amasiado e tem duas filhas, trabalhava numa distribuidora de alimentos. Declarou que já foi processado por um roubo com o Ricardo Javanovite, onde foram réus confessos, pegou dois anos e oito meses. Acrescentou que nesse assalto jogaram outros assaltos no depoente, mas não cometeram os outros assaltos. Falou que quando foram presos, na delegacia o policial falou que tinham roubado a família errada e por terem feito isso nunca mais iam pisar o pé em Arujá, porque ele iria acabar com suas vidas. Aduziu que foram réus confessos no outro processo em que foram presos, mas nos demais processos não tem como confessar. Disse não poder afirmar se o Ricardo é inocente ou não, mas ele falou para o depoente que também não estava envolvido nos demais roubos. Falou que no roubo em que foi condenado pegou dois anos e oito meses e no roubo dos autos nega a absolvição.

Essa foi a prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Ao cabo da instrução processual verifica-se a fragilidade probatória, sendo insuficiente a embasar a condenação dos réus pelo crime descrito na denúncia, tanto assim o é que o próprio Órgão acusador pleiteou a improcedência da pretensão

punitiva nas alegações finais, sendo seguido pelas defesas que pleitearam a absolvição diante da lacuna probatória.

Ainda que a vítima tenha realizado o reconhecimento fotográfico em solo policial, não foi ela ouvida em Juízo a fim de confirmar suas alegações, não sendo admitida a condenação tão somente com base nos elementos colhidos no inquérito policial ante a ausência de exercício do contraditório, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Saliente-se que embora a vítima tenha reconhecido os acusados por fotografia na delegacia, não houve reconhecimento pessoal na delegacia ou em juízo, inexistindo ainda outras provas que apontem serem os réus os autores do fato.

Em suma, não há qualquer prova nos autos a indicar que os réus tenham de fato praticado o delito que lhes fora imputado, à exceção do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima em solo policial, o que evidentemente não é suficiente para autorizar a prolação de um édito condenatório, mormente porque tal reconhecimento restou isolado nos autos.

Vale dizer que tal reconhecimento feito extrajudicialmente, sem participação da defesa e sem preenchimento dos requisitos do artigo 226 do CPP carece de força probante.

Ainda que a vítima tenha "reconhecido" os réus por meio das imagens, é preciso ter em conta que tal certeza é uma condição subjetiva que não se transmite automaticamente aos destinatários da prova, que são o juiz e as partes.

Dito de outro modo, o fato de a vítima ter certeza sobre quem reconhece não significa que o juiz e as partes também tenham essa certeza. Não se transmite a condição subjetiva do ofendido para os demais. Isso ocorre porque aquele que é vítima de fatos violentos, automaticamente e aqui isso de fato é automático sofre descargas bioquímicas que podem alterar a sua percepção sobre a realidade vivenciada, fazendo com que possa conservar, desde então, memórias alteradas.

Em termos investigativos, trata-se o reconhecimento de prova que deve ser analisada em conjunto com os demais elementos produzidos nos autos, como quais deve estar em harmonia, o que não ocorreu no caso dos autos, não passando despercebidas as falhas no procedimento adotado.

O que a vítima ou a testemunha diz sobre o fato não é necessariamente a verdade real, mas sim uma representação que guarda sobre o fato. Pode ser uma representação muito próxima ou muito distante do que realmente ocorreu, havendo risco de se tratar de falsas memórias.

Nesse passo, destaco recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, conduzido por um paradigmático voto do Min. Relator Rogério Schietti Cruz (HABEAS CORPUS Nº598.886 SC, julgado em 27.10.2020), no qual afirma que "o valor probatório do reconhecimento, portanto, deve ser visto com muito cuidado, justamente em razão da sua alta suscetibilidade de falhas e distorções. Justamente por possuir, quase sempre, um alto grau de subjetividade e de falibilidade é que esse meio de prova deve ser visto com reserva".

A propósito:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos

deletérios e muitas vezes irreversíveis. 3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato. 5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciais e, conseqüentemente, de graves injustiças. 6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II). 7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado. 8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo "processualmente admissível e válido" (Figueiredo Dias). 9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as inconsistências do suposto reconhecimento - sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo - ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado. 10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua conseqüente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado. 11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito - conforme reconheceu o Magistrado sentenciante - emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do local do delito na

posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo. É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (participação de menor importância). 12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa. Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação. (HABEAS CORPUS Nº 598.886 - SC - RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ).

Obviamente não se está afirmando que a vítima mentiu. Apenas se considerando a possibilidade de erro, que não seria incomum neste tipo de prova. Aliás, como oportunamente destaca Gustavo Badaró, "o reconhecimento pessoal já foi apontado como a mais falha e precária das provas. A principal causa de erro no reconhecimento é a semelhança entre as pessoas." (2016, p.483).

Também sobre o reconhecimento, destaca Fernando da Costa Tourinho Filho: "O reconhecimento é, de todas as provas, a mais falha, a mais precária. A ação do tempo, o disfarce, as más condições de observação, os erros por semelhança, a vontade de reconhecer tudo, torna o reconhecimento uma prova altamente precária". (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, ed.14ª, Ed. Saraiva, São Paulo: 2011, p. 622).

A respeito do valor do reconhecimento como prova, Guilherme de Souza Nucci também esclarece: O juiz jamais deve condenar uma pessoa única e tão-somente com base no reconhecimento feito pela vítima, por exemplo, salvo se essa identificação vier acompanhada de um depoimento seguro e convincente prestado pelo próprio ofendido, não demovido por outras evidências. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed, Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo: 2008, p. 500).

Além do mais, como bem pontuado pelo Ministério Público, os policiais ouvidos pouco recordaram acerca dos fatos, limitando-se a afirmar que a vítima efetuou o reconhecimento fotográfico.

Em acréscimo, ouvido em Juízo, o réu Thiago negou o cometimento do delito, afirmando que lhe foram imputados outros crimes pelos policiais os quais não cometeu, ao passo que o réu Ricardo não foi ouvido, não tendo sido localizado. Diante de tal quadro, levando-se em conta a carência probatória e ainda que restam

dúvidas quanto a quem de fato teria praticado o roubo, impõe-se a absolvição no caso em tela.

Registre-se que aos réus não incumbe a prova de sua inocência, sendo do Ministério Público o ônus de comprovar, de maneira robusta, a sua culpabilidade.

Forçoso, in casu, verificar que, não havendo qualquer outra prova que confirme a prática do crime descrito na denúncia pelos réus, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo em favor dos acusados, de modo a permitir que estes sejam absolvidos da imputação que lhes fora direcionada.

Como se vê, os elementos amealhados no curso da instrução penal não permitem concluir com um mínimo de segurança que os acusados efetivamente praticaram o crime em tela, visto que o conjunto probatório produzido não se mostra firme o bastante para lastrear uma condenação.

Como é cediço, em casos de dubiedade, de provas colidentes ou de insuficiência probatória, o respeito à máxima da presunção de inocência impõe a absolvição da acusada como medida de justiça. Sobre a presunção de inocência, manifesta-se Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional, vol I. Rio de Janeiro:Lumen Juris, 2008, p.178/19):

...é princípio fundamental de civilidade, fruto de uma opção garantista a favor da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que para isso tenha-se que pagar o preço da impunidade de algum culpável. Isso porque, ao corpo social, lhe basta que os culpados sejam geralmente punidos, pois o maior interesse é que todos os inocentes, sem exceção, estejam protegidos.

Se é verdade que os cidadãos estão ameaçados pelos delitos, também o estão pelas penas arbitrárias, fazendo com que a presunção de inocência não seja apenas uma garantia de liberdade e de verdade, senão também uma garantia de segurança (ou de defesa social), enquanto segurança oferecida pelo Estado de Direito e que se expressa na confiança dos cidadãos na Justiça. É uma justiça que se oferece ao arbítrio punitivo.

Assim, mesmo que implique a absolvição de um culpado, a presunção da inocência deve ser integralmente aplicada quando nos autos não subsiste a certeza indispensável à prolação de um decreto condenatório, sendo certo que muito mais grave e deletério a um Estado Democrático de Direito do que soltar um culpado é impor a um inocente uma condenação penal e submetê-lo aos rigores e amarguras de uma pena privativa de liberdade.

A responsabilidade penal deve estar estreme de dúvidas e não pode ser atribuída a um sujeito de maneira precipitada. É preciso que as provas carreadas aos autos demonstrem de forma inequívoca que o acusado foi do crime, de maneira que seja possível lhe imputar a prática do delito, o que não ocorreu no caso em questão. Fato é que, sem a taxatividade própria do direito penal, impossível exarar decreto condenatório, até mesmo porque:

“O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação” (Ac. un. da 5a. Câ., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313

Isto posto e por tudo mais que dos autos costa, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e ABSOLVO os réus THIAGO HENRIQUE LEITE e RICARDO JAVANOVITE, qualificados nos autos, das imputações que lhes foram dirigidas, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Expeça-se certidão de honorários aos patronos nomeados pela OAB/DPE.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, indevida a condenação dos réus ao pagamento das custas finais, haja vista que não foram condenados.

P.I.C.

Aruja, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA